

0001357-81.2020.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Marcos Vinicius Costa da Silva

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Marcos Vinicius Costa da Silva, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

0001357-81.2020.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001357-81.2020.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Marcos Vinicius Costa da Silva

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Marcos Vinicius Costa da Silva, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 119/120).

Determinou-se o processamento (fls. 151/153).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 199), apresentou resposta escrita

(fls. 202/204). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2021 (fls. 222/224) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 239).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 06/08 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 [AEA]), do laudo pericial toxicológico definitivo (fls. 26/28 [LPTox]) e do laudo pericial telefônico (fls. 209/214 [LPTel]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Tiago Alessi, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "receberam denúncia anônima de que indivíduo de vulgo 'Tico' sairia para entregar drogas perto do 'campo'; que, então, para lá se dirigiram e avistaram o apontado, o qual, ao visualizar a viatura, dispensou ao solo uma porção de maconha, a qual, pesada nesta Unidade, resultou em aproximadamente 21,90 gramas; que, então, perceberam que o apontado se evadiu sentido à sua residência e também foram para lá; que, ao chegarem no imóvel, inicialmente, o irmão do investigado disse que 'Tico' ali não estava, mas este logo apareceu e disse que havia mais droga no imóvel; que, então, em revista ao imóvel, localizaram, dentro de uma sacola que se encontrava no tanque, R\$74,00 (setenta e quatro reais) em dinheiro, além de uma balança de precisão e o restante da maconha; que o apontado confirmou que havia saído de casa para entregar a maconha por ele dispensada, em troca de R\$ 100,00 (cem reais); que, somada o peso da droga dispensada pelo apontado, na rua, com aquela encontrada em sua casa, resultou-se, aproximadamente em 114,6 gramas de maconha; que, diante disso, deram voz de prisão em flagrante ao indiciado, conduzindo-o a este Plantão Policial". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha José Alberto Alves Bittencourt, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "receberam denúncia anônima de que indivíduo de vulgo 'Tico' sairia para entregar drogas perto do 'campo'; que, então, para lá se dirigiram e avistaram o apontado, o qual, ao visualizar a viatura, dispensou ao solo uma porção de maconha, a qual, pesada nesta Unidade, resultou em aproximadamente 21,90 gramas; que, então, perceberam que o apontado se evadiu sentido à sua residência e também foram para lá; que, ao chegarem no imóvel, inicialmente, o irmão do investigado disse que 'Tico' ali não estava, mas este logo apareceu e disse que havia mais droga no imóvel; que, então, em revista ao imóvel, localizaram, dentro de uma sacola que se encontrava no tanque, R\$74,00 (setenta e quatro reais) em dinheiro, além de uma balança de precisão e o restante da maconha; que o apontado confirmou que havia saído de casa para entregar a maconha por ele dispensada, em troca de R\$ 100,00 (cem reais); que, somada o peso da droga dispensada pelo apontado, na rua, com aquela encontrada em sua casa, resultou-se, aproximadamente em 114,6 gramas de maconha; que, diante disso, deram voz de prisão

em flagrante ao indiciado, conduzindo-o a este Plantão Policial." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 05).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava a comercializar drogas. Por dificuldade financeira, decidiu fazê-lo. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual] ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaulo Poggio.

Legislação penal especial. 7.^a edição - São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 - nova lei de drogas. - 4.^a edição - São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada - comentários à lei n. 11.343/2006. - 9.^a edição - São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.^a edição - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF - Primeira Turma - Habeas Corpus 69.806-GO - Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP - 2.^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO - ACrim. n. 33578-9/213 - Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP - 7.^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP - 13.^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP - 3.^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP - 6.^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência

e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 - Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

No presente caso dos autos, as drogas periciadas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo e guardava, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Com relação ao contexto fático processado e julgado, saliento, a infração foi cometida nas dependências ou imediações de recinto onde se realizava diversões (atividades de entretenimento recreativo e esportivo) de qualquer natureza (campo de futebol municipal) (art. 40, III, da LD [circunstância descrita na denúncia]), dado que extraio das declarações dos agentes de segurança pública.

A configuração da causa de aumento de pena descrita no art. 40, III, da LD, que tem por circunstância as imediações de locais especialmente protegidos, não depende da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades (STJ - Quinta Turma - AgRg no HC n. 583.833-SP - Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item IV da ementa]; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501944-97.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Estância Turística de Comarca de Olímpia - Rel. Des. CÉSAR MECCHI MORALES, V.U., j. 12/01/2021, p. 07 [índole objetiva]).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500036-97.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 26/04/2022, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 10/11; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 11; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500422-78.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, V.U., j. 02/06/2022, p. 15; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500639-10.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO SALE JÚNIOR, V.M., j. 15/06/2022, p. 15/17), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia,

adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável), e sem ordem não há progresso.

Nos termos do art. 24, caput, do CP, "considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se", de modo que, no presente caso dos autos, ao comparar os bens salvo (dificuldade financeira [sic], de interesse particular) e sacrificado (saúde pública, de interesse da sociedade), este é de maior importância que aquele, o que afasta, pelo princípio da ponderação de bens, a "inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado" (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 04).

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas circunstanciado (art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Não há registros criminais (fls. 242/246), verifico.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade e (ii) a quantidade das drogas são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e

666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis attractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, “enxugadores de gelo”, pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 [“Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênia, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido.”]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 10; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j.

07/10/2019, p. 04; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500017-62.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 11/04/2022, p. 18/19; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 10/11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501791-30.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLAUDIO LIMA BUENO DE CAMARGO, V.U., j. 10/02/2022, p. 03/04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da

Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Da quantidade das drogas: No entender deste magistrado, a apreensão de expressiva (significativa) quantidade de drogas deve ser considerada (STJ - Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Min. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ - Quinta Turma - Habeas Corpus 409.324/MS - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501484-76.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 11/05/2022, p. 14; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 7; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10 [71,900g de maconha]; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) anos (fls. 12 [Boletim de Identificação Criminal] e 13 [Carteira de Identidade]), na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ), e confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizada a segunda circunstância com a terceira (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001443-91.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. DINIZ FERNANDO, V.U., j. 27/08/2018; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001230-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. NILSON XAVIER DE SOUZA, V.U., j. 15/05/2019, p. 03; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001125-74.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CAMARGO ARANHA FILHO, V.U., j. 16/04/2019, p. 06), fixo a pena provisória, com atenuação de 1/3 (um terço), em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (Súmula 231 do STJ).

Respeitado entendimento diverso, o tratamento diferenciado da circunstância atenuante da jovialidade - a qual se refere à personalidade do agente, no entender deste magistrado - é justo, proporcional, razoável e, sobretudo, constitucional (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 16ª Câmara de

Direito Criminal – Apelação n. 1500451-65.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. NEWTON DE OLIVEIRA NEVES, V.U., j. 02/02/2021, p. 09 [1/3]).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, de acordo com o art. 68, parágrafo único, do CP (princípio da incidência acumulada), incidirá primeiramente a causa constante da Parte Especial, por sua maior especificidade, e, depois, a da Parte Geral.

Pela ordem.

Com relação à CAUSA INCIDENTE PRIMARIAMENTE, reconheço ser a parte ré primária e de bons antecedentes (conforme Folha de Antecedente e Certidões), de um lado, e, por outro, não existe prova suficiente de dedicação às atividades criminosas, nem de integração de organização criminosa (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 2/3 (dois terços) (STF – Plenário – AgRE n. 666.334 – Repercussão Geral – 3ª V. E. C. U. T. E. da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas – Min. Rel. GILMAR MENDES, j. 3/04/2014; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001043-14.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS MONNERAT, V.U., j. 27/10/2016), em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

De acordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (STF – HC n. 209.023/MG – Rel.ª Min.ª CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, j. 19/11/2021, p. 08), com o qual concordo, a utilização da natureza e da quantidade da droga (substância ou produto) na primeira fase e na terceira fase da fixação das penas, para definir o percentual da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da LD, caracterizaria o bis in idem.

Com relação à CAUSA INCIDENTE SECUNDARIAMENTE, reconheço que a infração foi cometida nas dependências ou imediações de recinto onde se realizavam diversões (atividades de entretenimento recreativo e esportivo) de qualquer natureza (campo de futebol municipal) (art. 40, III, da LD), de modo que, nos termos do art. 40 da LD, fixo a pena provisória, aumentando-a de 1/6 (um sexto), em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2.4 Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO (STJ – Habeas Corpus n. 596.603-SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37: "X. Dispositivo [...] 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. [...]"; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500483-90.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 18/01/2021, p. 11), porque, apesar da primariedade, as circunstâncias não são favoráveis (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002372-56.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 02/05/2020, p. 07), o que reputo

motivação idônea para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF)

2.5 Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, caput e § 2º, parte final (in fine), do CP, PODE EXCEPCIONALMENTE ser substituída por DUAS restritivas de direitos, consistentes, a primeira, em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 46 do CP, pelo mesmo prazo da pena substituída, e, a segunda, em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social desta Comarca, nos termos do art. 45, § 1º, do CP.

Contextualizo, com efeito, a exceção.

Apesar das circunstâncias desfavoráveis, entendo que a substituição, neste caso, é medida socialmente recomendável (inteligência do art. 44, § 3º, do CP) (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500098-88.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 13/10/2021, p. 04 [... acertada a substituição da pena corporal por restritivas de direito fixadas pelo juízo 'a quo'.]); TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto – Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1503051-79.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SÉRGIO RIBAS, V.U., j. 16/09/2021, p. 04; TJSP – 12ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000215-95.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JOÃO MORENGHI, V.U., j. 23/05/2018, p. 03), tendo em vista que cadeia não conserta ninguém; trabalho, sim, "porque digno é o trabalhador do seu alimento" (Mateus, 10:10).

No entender deste magistrado, alguns fatores recomendam a substituição da pena aplicada por outra espécie, a saber: (x) a parte ré era jovem adulto por ocasião dos fatos (art. 65, I [jovialidade adulta], do CP); (x) a parte ré confessou espontaneamente, perante o Estado-Juiz, a autoria do crime (art. 65, III, d, do CP); (x) a parte ré está arrependida, pois, no sentir deste magistrado (feeling), mudou deveras (verdadeiramente) de comportamento em relação ao que já aconteceu (ocupação formal lícita [com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS], hoje); (x) os requisitos cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da LD estão presentes (cf. item 2.3); e (x) o objeto do contexto criminoso processado e julgado (maconha, no caso vertente) não se trata de "cocaína" ou "crack" (subproduto da "cocaína" [droga dentre as piores espécies que existem]).

Não há falar em incompatibilidade entre a substituição da pena aplicada por outra espécie e o regime inicial fechado ou semiaberto de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois, de um lado, o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP trata de regime penitenciário e, de outro, o art. 44, caput, do CP disciplina espécie de pena.

2.6 Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, III (cabimento da substituição) (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003115-71.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA, V.U., j. 18/10/2021, p. 05), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7 Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas (fls. 130/131), poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solto condicionalmente (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012: "É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." [grifei]).

2.8 Dos efeitos da condenação

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 14).

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficie-se, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, a, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos do crime apreendidos com a parte ré (AEA), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito; conseqüentemente (art. 119 do CPP), determino, nos termos do art. 124 do CPP, a inutilização desses instrumentos (destruição).

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos desta Comarca cópia do auto de exibição e apreensão (AEA) e do termo de registro de objeto (TRD).

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Marcos Vinicius Costa da Silva, portadora do RG n. 54.378.772 - SSP/SP, como incurso no art. 33, § 4º (Comunicado CGJ SP n. 121/2017), c.c. o art. 40, III, da LD, às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (STJ - Habeas Corpus n. 596.603-SP - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37); além de confiscar os bens apreendidos (item 2.8).

3.1 Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, mandado de prisão em desfavor da parte ré; com o cumprimento do mandado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3 Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

3.5 Da certidão de honorários advocatícios

Não há certidão a ser expedida.

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 22 de junho de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)